

1500633-47.2022.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA

ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. "1. Em razão da política criminal adotada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000, Fone:

(14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500633-47.2022.8.26.0201

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3033775/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MILTON ALEXANDRE BENITEZ

Vítima:

SAUDE PÚBLICA

Aos 20 de outubro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, fez-se presente na sala virtual durante a realização do ato, o(a) representante do Ministério Público Dr(a). Lysaneas Santos Maciel; o(a) acusado(a) Milton Alexandre Benitez (em sala própria na Penitenciária de Álvaro de Carvalho), acompanhado do(a) defensor(a) Dr(a). Diogo Simionato Alves; e a testemunha Luiz Fernando Kossisky. Cumprir observar que antes do início da audiência foi oportunizada conversa privativa entre o(a) acusado(a) e seu(ua)(s) defensor(a)(s). INICIADOS OS TRABALHOS, dada a palavra ao(à) defensor(a) para apresentação da defesa preliminar, assim se manifestou: "MM(a). Juiz(a): A denúncia não deve ser recebida, pois não há elementos probatórios suficientes. Não sendo este o entendimento, a inocência do acusado será demonstrada durante a instrução processual.". A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte decisão: "RECEBO A DENÚNCIA, pois há indícios de materialidade e autoria, não vislumbrando nenhuma das hipóteses de rejeição, merecendo os fatos a sua apuração em contraditório". Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi realizada a oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s)

pelas partes Luiz Fernando Kossisky, sendo esta(s) regularmente identificada(s) e desconectada(s)/retirada(s) da sala logo após seu(s) depoimento(s). Após foi realizado o interrogatório do acusado(a)(s). Sem que tenha havido qualquer oposição, todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados no próprio termo de audiência SAJPG5, além do repositório em nuvem através do sistema One Drive, nos termos do item 12 do Comunicado Conjunto nº 284/2020 e das Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o(a) MM. Juiz(a) declarou encerrada a instrução, passando a palavra à acusação e à defesa para os debates orais. Pelo representante do Ministério Público foi apresentada suas alegações orais. Pelo(a) defensor(a) foi solicitado que pudesse realizar as alegações escritas encaminhando-as através do "chat" da audiência virtual, sendo deferido pelo MM. Juiz de Direito, alegações estas de seguinte teor: "Trata-se de denúncia ofertada pelo M.P. por incurso do réu ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Segundo apurou-se, em revista pessoal ao apenado em sua cela, logrou-se apreender nas vestes íntimas do agente, a droga retro indicada. Abe-se que o depoimento do agente penitenciário, não é suficiente à condenação quando em desarmonia com as demais provas existentes nos autos, por isso, ausente a prova contundente do delito, justifica-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Mesmo admitindo-se, a título de argumentação, de que o réu detivesse para uso próprio, produto estupefaciente, tal conduta é descriminalizada conforme artigo 28 da lei 11.343/06, in verbis: "Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo." O réu pode, portanto, apenas ser advertido sobre os efeitos das drogas e convidado a comparecer em programa ou curso educativo, mesmo com relação a prestação de serviços à comunidade em caso de descumprimento, a sanção por sua desídia é a admoestação verbal e a aplicação de multa, conforme o parágrafo 6º do artigo 28 da lei 11.343/06, in verbis: "§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: I - admoestação verbal; II - multa." Ocorre a descriminalização do porte para uso próprio de produto entorpecente, pois não é considerado crime, embora continue com caráter ilícito de ato contrário ao direito, conforme artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal brasileiro - Dec.-Lei 3.914/41, in verbis: "Art. 1º Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente." grifo nosso

ISTO POSTO, REQUER: I.- Seja reconhecida a descriminalização do artigo 28 da lei 11.343/06, repelindo-se, por consequência a denúncia. II.- Seja absolvido o réu, frente ao sofrível e defectível conjunto probatório hospedado aos autos, impotente em si e por si para lastrear um juízo condenatório. Nesses Termos Pede Deferimento. A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. MILTON ALEXANDRE BENITEZ, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03); pelos termos de declarações (fls. 15/16); auto de exibição/apreensão (fl. 07); pelo laudo pericial (fls. 11/14); e pela prova oral colhido em juízo. A autoria também é certa e recai sobre o acusado. Em solo policial, a testemunha LUIZ FERNANDO KOSSISKY declarou: Que o depoente trabalha como agente de segurança penitenciário na penitenciária local, sendo que na data dos fatos, ao realizar uma revista no sentenciado MILTON ALEXANDRE BENITEZ, o depoente veio a localizar

ocultado dentro de sua cueca 01 (um) invólucro plástico contendo em seu interior substância semelhante a entorpecente "maconha". Que ao ser indagado, referido sentenciado assumiu a propriedade do entorpecente, porém, não deu detalhes de como teria adquirido. (fl. 15). EM JUÍZO, declarou que, no dia dos fatos, pós-retorno da saída temporária. Os sentenciados foram abordados e foi encontrado na cueca do Milton um invólucro com suspeita de maconha. O sentenciado falou que a droga era dele. O depoente nunca teve nenhuma desavença com o acusado. Durante o interrogatório em solo policial, o acusado MILTON ALEXANDRE BENÍTEZ declarou: "Que está nesta Unidade Prisional, desde 07 de novembro de 2018, procedente do CDP de Bauru - SP. Respondeu que os fatos descritos no comunicado de evento são verdadeiros. Respondeu que no dia dos fatos devido ao retorno da última saída temporária no núcleo de inclusão servidores localizaram de modo oculto na cueca que o declarante vestia 01 (um) invólucro plástico com maconha. Respondeu que achou a referida droga em meio a lixo dispensado na cela pelos sentenciados. Respondeu que devido ser usuário de drogas pegou a droga para seu consumo, porém, demonstra arrependimento. Respondeu não sabendo informar como a referida droga adentrou na Unidade Prisional. Respondeu que não deseja arrolar testemunhas. Aberta oportunidade de manifestação do nobre advogado da Funap este nada acrescentou". (fl. 16). DURANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL, o acusado confessou que encontrou a porção de maconha e que estava com ela no momento da revista, sendo, posteriormente, localizada pelo agente penitenciário. Pois bem. Analisando o conjunto probatório, entendo que a prova coligida nos autos é suficientemente segura para a expedição de condenatório em desfavor do acusado. O agente penitenciário relatou que, na data dos fatos, durante revista pessoal, foi encontrado com o acusado um invólucro contendo maconha. É cediço que a palavra dos agentes penitenciários, quando coerentes com os elementos trazidos aos autos, é apta para comprovar a prática da infração penal. Nesse sentido: "A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a Documento: 84098549 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral." (HC 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. Considerando a pequena quantidade da droga encontrada com o acusado, dissociada de outros elementos aptos a indicar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, entendo que a conduta do acusado encontra tipicidade exata no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. "1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no RHC n. 147.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.) De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202;

TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306). No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015). Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência ao acusado. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado MILTON ALEXANDRE BENÍTEZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA. Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames. Após o trânsito em julgado, realize as anotações de praxe e, se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.". Após a prolação da sentença pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença. Pelo DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM(a). Juiz(a) de Direito, a seguir, foi dito: "Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, razão pela qual, com fulcro no princípio da celeridade, realizarei a advertência do acusado quanto aos malefícios das drogas, dando cumprimento a sentença proferida. Expeça-se a competente certidão de honorários, nos termos do convênio Defensoria/OAB-SP.". Na sequência o MM. Juiz de Direito advertiu o acusado quanto aos efeitos nocivos do uso das drogas, tendo proferido a seguinte decisão: "Em razão do cumprimento da pena de advertência contida no artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06 aplicada e ainda diante da manifestação do representante do Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do(a) sentenciado(a) MILTON ALEXANDRE BENÍTEZ, nos termos do artigo 66, II da Lei de Execução Penal. P.I.C. Providencie a z. Serventia as anotações e comunicações de praxe, após arquivem-se os autos digitais.". Sentença e decisões proferidas em audiência, saem os presentes intimados. Nada Mais. Eu, Reginaldo Luiz Parente, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA